

1506878-06.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186332/2021 - DEL.POL.SALTO, 18970903 - DEL.POL.SALTO, 1839/21/610 - DEL.POL.SALTO, 2186332 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAFAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506878-06.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506878-06.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186332/2021 - DEL.POL.SALTO, 18970903 - DEL.POL.SALTO, 1839/21/610 - DEL.POL.SALTO, 2186332 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 40, incisos inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), da Lei Federal nº 11.343/06 e com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 11 de julho de 2021, por voltas das 18 horas, na Rua Senador Vergueiro, nº 19, Jardim Santa Cruz,

nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado vendeu a Ageu Leandro de Assis (fls. 05), guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 02 (duas) porções de "cocaína", com peso líquido de 0,60g (sessenta centigramas); e b) 09 (nove) porções de "cocaína", com peso líquido 2,88g (dois gramas e oitenta e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 23 de setembro de 2021 (fls. 76-80).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls.98-99).

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022 (fl. 104-105).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas três testemunhas.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, sendo que o réu é usuário, alternativamente, postulou a desclassificação do delito. Finalmente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls.09-12), auto de exibição e apreensão (fl.13), auto de constatação preliminar (fls.14) e laudo de exame químico toxicológico (fls.68-71) bem como por toda prova oral coligida nos autos. A autoria do crime de tráfico também é certa.

Observado o artigo 155 do Código de Processo Penal, anoto que Ageu Leandro de Assis, disse na fase policial (fls. 05), em síntese, que estava no local comprando drogas, tendo entregue duas notas de R\$20,00 (vinte reais) e uma nota de R\$50,00 (cinquenta reais) a um indivíduo desconhecido e recebeu 9 (nove) porções de cocaína. Surgiu uma viatura da GCM e o abordou. Não viu a GCM abordar o outro indivíduo e não tem condições de reconhecer se foi ele quem lhe vendeu drogas. É usuário de drogas e foi abordado no momento em que havia acabado de comprar as drogas.

Os guardas municipais Diego Guiaro de Moraes e Claudemir Tenório da Silva foram uníssomos ao relatar em Juízo que estavam em patrulhamento no Bairro Jardim Santa Cruz perto da Praça do Macaia, ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando viram dois indivíduos negociando, trocando, algo. Eles começaram a andar rápido e se separaram, porém foram abordados. A abordagem foi realizada na via pública, próximo à praça. A negociação vista pelos guardas ocorreu em local próximo da abordagem. Com Rafael foi encontrado R\$ 90,00 (noventa reais) sendo uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e duas de R\$ 20,00 (vinte reais) e dois microtubos com cocaína, na jaqueta. Rafael alegou ser usuário e disse que o dinheiro era proveniente do seu serviço. Ageu declarou que comprou 9 microtubos de substância similar a cocaína que estavam em seu poder, pagando R\$ 90,00 (noventa reais) sendo composto por uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e duas notas de R\$ 20,00 (vinte reais) mas não indicou o vendedor.

O réu Rafael Henrique dos Santos, interrogado judicialmente, disse, em resumo que havia comprado duas porções de cocaína para seu uso quando foi abordado pelos GCMs. Estava na posse das porções de cocaína e 90 reais em dinheiro. Não vendeu drogas a Ageu. Não o conhece e não correu dos policiais. Não passou dinheiro ou droga a Ageu.

Como se vê, os relatos apresentados pelos guardas municipais demonstram que, em conformidade com a denúncia, o réu foi flagrado entregando o entorpecente e recebendo quantia em dinheiro ao usuário Ageu, afastando-se, assim, a tese do consumo pessoal. Nota-se, ainda, que submetido à revista pessoal, com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 90,00 (noventa) reais, ao passo que Ageu afirma que pagou exatamente R\$ 90,00 (noventa reais) pelas 9 (nove) porções de cocaína encontradas em sua posse, o que permite concluir pela traficância.

O simples fato de o réu alegar ser usuário ou possuir outra fonte de renda lícita não a impede de exercer a traficância, o que também não se mostra incomum.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a

condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por via próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda,

32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos em via pública, próximo a uma praça (fls. 88-89), local que além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza". Ainda, não restou demonstrado que o local ensejava a aglomeração de grande número de pessoas. Pelo contrário, os guardas municipais afirmaram que a praça é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

Cabe salientar que não constituem maus antecedentes: ações penais que resultaram em absolvição (STJ HC 360123/SP), processos criminais extintos sem resolução de mérito, condenações por crimes militares próprios e políticos, em interpretação analógica extensiva a regra do inciso II do artigo 64 do Código Penal; procedimentos acerca de fatos ocorridos quando o acusado era menor de idade (STJ HC 81866/DF); condenações definitivas por fatos ocorridos após aquele que está em julgamento; punições impostas em procedimentos administrativos; sentença homologatória de transação penal ou sentença homologatória de reparação civil de danos; decisão que suspende condicionalmente o processo e posterior sentença extintiva da punibilidade do agente; sentença concessiva de perdão judicial (súmula 18 do STJ). Nesse ínterim, anoto que não serão valoradas negativamente as sentenças de extinção da punibilidade pela concessão da suspensão condicional do processo e transação penal (fls. 118-119).

Por fim, o Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 02 (duas) porções de "cocaína", com peso líquido de 0,60g (sessenta centigramas) e 09 (nove) porções de "cocaína", com peso líquido 2,88g (dois gramas e oitenta e oito centigramas), a concessão da transação penal (Art. 76 da Lei 9099/95) e suspensão condicional do processo (Art. 89 da Lei 9099/95), não são consideradas como maus antecedentes ou reincidência, o réu é primário (fls. 118-119) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de

crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Não há outras circunstâncias a serem avaliadas na aplicação da pena.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA